

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 1A
NOMINACIÓN DE CÓRDOBA

-----R., P. A.----- c. ----M., C. L.----- y otros • 21/07/2003

2ª Instancia.- Córdoba, julio 21 de 2003.

1ª ¿Proceden los recursos de apelación de ambas partes? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. - El doctor *Sarsfield Novillo* dijo:

I. En contra de la Sentencia del Inferior que resolvía en la forma en que ha quedado transcrito en el exordio del presente, apelan ambas partes y la concesión de los remedios articulados hace radicar la causa en esta Sede.

II. En la estación procesal correspondiente, los recurrentes exponen sus quejas. II. 1. El representante de los demandados, reprocha la desestimación de la excepción de falta de personería de la accionante pues cuando esta se acreditó se había vencido el plazo otorgado a la sucesión del demandante para hacerlo, sosteniendo que la argumentación del a quo contraviene las disposiciones de los arts. 1960 y 1962 del Cód. Civil.

Dice que "... la circunstancia de haberse otorgado un poder para pleitos durante la vigencia encuadra dentro de la norma citada en segundo término. Los perjuicios y zozobras que produce la inexistencia de mandato y la sanción legal son razones suficientes para que la excepción articulada sea acogida. Toda otra consideración hace al tratamiento desigual efectuado a los garantes al no aceptársele un mandato otorgado por ante el Juzgado de Tránsito y autorizado por la Secretaria judicialmente funcionando. Razones establecidas en las normas legales citadas tornan procedente la excepción articulada y dejan huérfano de razonamiento legal a las conclusiones del a quo".

Se agravia, también, por el rechazo de la excepción de inhabilidad de título.

Al respecto, sostiene que nada se adeuda al actor fuera del plazo contractual. Afirma que "... es el actor quien debe probar la subsistencia de la locación y cobertura del contrato equivocándose al requerir la presentación de recibos; pero si es del caso que hemos negado ser continuadores de la locación concluida, mal se puede pretender exhibamos recibo de tal plazo. Ello es una prueba diabólica e imposible de producir en honor a la congruencia que los hechos imponen. Consideramos arbitrariedad pretender el cobro de alquileres por plazos extensos después de haber vencido el contrato; máxime cuando se carece de contrato escrito en los términos de la ley 23.091. Tal arbitrariedad ha sido receptada legislativamente en oportunidad de tratarse la limitación de la responsabilidad de los garantes por ley 25.628. Allí se concentró las razones que por abuso de derecho, transparencia, y demás conductas hacen que los periodos reclamados no puedan ser atendidos...", (ver fs. 116/117).

II. 2. El apoderado de la parte ejecutante, contesta el traslado que se le confiriera denunciando la inexistencia de "expresión de agravios" y reclamando, en forma subsidiaria, el rechazo de la apelación. En la oportunidad, pide la aplicación de la sanción prevista en el art. 83 de la ley ritual, (ver fs. 123/125).

II. 3. El mismo mandatario, expresa sus agravios relacionados con la condena al pago, en concepto de interés, de la suma que resulte de calcularlo sobre la base de una tasa del dieciocho por ciento anual por todo concepto.

Asegura que con motivo de la depreciación de nuestro signo monetario a partir del mes de enero del año próximo pasado, corresponde aplicar un índice de actualización monetaria a fin de no envilecer su acreencia y, en ese orden de ideas, pide la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 para el supuesto caso en que fuera necesario toda vez que puede, sostiene, ordenarse una recomposición de la prestación

sin llegar a ese extremo por el expediente de la imposición de mayores intereses desde la fecha recién indicada morigerando la multa diaria convenida entre las partes en la cláusula séptima del contrato de locación (ver fs. 113/115).

II. 4. A la parte demandada se le da por decaído el derecho dejado de usar al no evacuar, en tiempo propio, el traslado que le fuera corrido (ver fs. 120).

II. 5. El pronunciamiento opugnado (ver fs. 94/100), contiene una adecuada relación de causa que junto a los escritos de las partes a los que se ha hecho referencia, se da por reproducida para satisfacer la exigencia del art. 329 del CPCC.

III. La Sentencia cuestionada se apeló por el doctor F. R. C. quien dijo hacerlo por Antonio Javier Rodríguez, Olga Isabel Franco, -----M., C. L.----- y ----O. C.----- . Los dos últimos fueron demandados en condición de locatarios y los dos primeros en calidad de fiadores.

Los Sres. Miretti y Castaña apoderaron al letrado mediante carta poder obrante a fs. 12. Respecto de los garantes, los decretos de fs. 16 y 25 evidencian que al docto R. C. no se le acordó la participación que requirió por los restantes.

Como los Sres. Rodríguez y Franco nunca comparecieron al juicio -fueron declarados rebeldes a fs. 28 por providencia que quedara firme y con posterioridad, no se presentaron-, el escrito de fs. 116 que lleva por título "Expresión de agravios" debe ser considerado como presentado por la representación de los otros codemandados, es decir, los Sres. Miretti y Castaña.

IV. El embate recursivo de los accionados, carece de argumentación dado que se limitó a la reiteración del planteo formulado en la instancia anterior.

En efecto, ello es así porque en el presente caso no se dan los supuestos que en doctrina se mencionan como imprescindibles para que el recurso se baste a sí mismo.

Sobre el punto, es bueno hacer algunas precisiones en lo que hace a la locución técnica: "expresión de agravios".

Cabe decir que por expresión de agravios se entiende el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia, respecto a la apreciación de los hechos y valoración de las pruebas, o a la aplicación de las normas jurídicas, (Palacio, Derecho Procesal, V, p. 266, N° 599).

Alsina, señala que "Por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama" (Derecho Procesal, t. IV, p. 389).

Fenochietto-Arazi, refieren que: "Constituye un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal" (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. I, p. 939).

Se ha dicho con relación al contenido de la expresión de agravios que "debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas no bastando las simples generalizaciones ni las apreciaciones meramente subjetivas que demuestren un enfoque diferente del otorgado por el juzgador".

Tampoco se cumple con las recordadas exigencias cuando el apelante manifiesta mera disconformidad con el fallo de primera instancia, que considera injusto, mas sin suministrar argumentos jurídicos que fundan un punto de vista diferente reiterando alegaciones ya efectuadas y examinadas por el a quo, (CNCiv., sala F, 14/2/85, La Ley, 1985-C, 644, 36.876-S); asimismo se ha señalado que "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia

apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación. No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso", (CNCiv., sala C, 17/12/83, La Ley, 1986-C, 642, 36.868-S).

De lo que se trata, en definitiva, es que no basta con simples pareceres; ni con sólo disentir, ya que la crítica -que es lo que debe llevarse a cabo al fundamentar el remedio- significa un ataque directo y pertinente a la cimentación del decisorio del a quo, y, en cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la decisión.

Dice H. Eduardo Sirkin en su trabajo "El recurso de apelación. Sus formas y efectos", (en "Medios de Impugnación. Recursos - I", p. 99, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999), al formular una cita, que "La argumentación del apelante tendiente a obtener una modificación de la sentencia anterior está lejos de constituir la "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas", tal como lo prescribe el art. 259 del ritual (nacional), si los presuntos "agravios" se ciñen a expresar sólo una disconformidad con lo sentenciado, con olvido de que "criticar" es un concepto muy distinto al de "disentir", pues mientras aquél importa un ataque directo y objetivo de la fundamentación, procurando la demostración de los errores contenidos en la misma, el segundo es meramente la exposición del desacuerdo con lo decidido", (CNCiv., sala A, 21/5/90, "R., O. C. c. R., A", La Ley 1992-A, 269, con nota de Alberto Jorge Gowland, y La Ley 1990-C, 576, Jurisp. Agrup, caso 7154; 16/3/90, La Ley 1990-C, 439 y DJ, 1990-2-821).

Tengo en cuenta lo que también enseña Julio L. Fontaine: "El apelante cumple con el traslado dispuesto por el Tribunal presentando el escrito de expresión de agravios. Esta pieza, como se ha dicho tantas veces, es al recurso lo mismo que la demanda es a la pretensión. Con él queda delimitado el ámbito del juicio de apelación que se contrae precisamente a los puntos que la sentencia de primer grado "a que se refieren los agravios" (art. 355)".

Y más adelante, dice: "... la expresión de agravios debe consistir, como resulta de su propia denominación, en una descalificación crítica de la decisión del juez. Expresar agravios es, en efecto, censurar, criticar, y no simplemente no estar de acuerdo. Por eso se exige al apelante que no se limite solamente a indicar cómo, a su juicio, habría debido resolverse el pleito; su deber es señalar razonadamente los errores que contiene la sentencia y la manera en que ellos inciden en la decisión para tornarla injusta... Basta para que haya agravio que la censura exista ...", (conf. "Código Procesal Civil y Comercial...", dirigido por Rogelio Ferrer Martínez, p. 656, Ed. Advocatus, Córdoba, 2000, y también la jurisprudencia citada por Mario Martínez Crespo, en su Código Procesal Comentado, p. 507, Ed. Advocatus, Córdoba, 2000).

Sobre el punto, he afirmado: "... el recurrente, en su escrito, debe analizar el pronunciamiento del Inferior señalando cuáles son los defectos que evidencia y lo hacen injusto.

En esa tarea, debe apuntar escrupulosamente todos los errores que contenga la sentencia.

Va de suyo que si la apelación procura el examen de este acto procesal, el ataque no puede basamentarse en argumentaciones vertidas con anterioridad a la producción de ese acto, por lo que debe consistir en marcar la equivocación del judicante en la valoración de la prueba o la correcta aplicación del derecho vigente", (conf. mis votos en las resoluciones dictadas en este Tribunal, Excma. Cámara Primera en lo Civil y

Comercial, Sentencia N° 10 del uno de marzo de mil novecientos noventa; Sentencia N° 67 del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa; Auto Interlocutorio N° 215 del cinco de julio de mil novecientos noventa; Auto Interlocutorio N° 56 del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, entre otras).

También, tuve oportunidad de sostener: "... el escrito de la parte recurrente, no es bastante para ser calificado como verdadera "expresión de agravios", en el sentido técnico de la locución, toda vez que no contiene una adecuada crítica del decisorio que ataca, omitiendo poner de relieve el error en que habría incurrido el juzgador respecto de la apreciación de la prueba aportada o de la aplicación del derecho vigente", (conf. mi voto en Sentencia N° 54 del seis de junio de mil novecientos noventa y seis en autos: "De Arapiles García, Luis c. Mateo Eduardo Seimandi - Ejecutivo").

Para el caso, asimismo, merece citarse esta jurisprudencia: La expresión de agravios debe bastarse a sí misma porque de lo contrario no constituye fundada réplica, ya que el agravio es la medida de la apelación, (CFedCordoba, sala A, 1986/08/12, "Banco de la Nación Argentina c. Baravalle, Juan C.", LLC, 987-192).

1. El tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión de todo lo actuado en la instancia de origen sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a través de los agravios del apelante. El juicio de apelación comienza con la expresión de agravios que hace las veces de una demanda dirigida a lograr la revisión del fallo de primera instancia.

2. Por ello, la expresión de agravios debe ser una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia, (CCCLyM de Comodoro Rivadavia, 22/4/96, interl., Merelle c. T. y B.).

La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, (CFCACap., 5ª, 14/2/96, Altamirano c. Universidad de Buenos Aires; CCCom., 2ª, QL, 15/10/97, Fugazza c. Odus SRL; CCCLyM de La Pampa, 1ª, 7/2/97, Demaría c. La Prontitud SRL; CCCyM de San Juan, 3ª, 5/9/96, Torres c. Petruzzi; CPL de San Juan, 6/2/97, Berroca c. Goycochea; íd., 11/8/97, Olguin c. Luis Lahoz), señalando punto por punto los errores en que ha incurrido (CCCLyM de Comodoro Rivadavia, 22/4/96, interl., Merelle c. T. y B.; CCCyM de San Juan, 14/10/97, Alvarado c. IPV), sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (CCCyM de San Juan, 3ª, 30/8/96, Sánchez c. IPSAS; íd., 24/10/96, Ramírez c. Corsunsky; íd., 24/6/97, Gómez s/Sucesorio; CAT de San Juan, 2ª, 1/4/97, Becerra c. ADOS) y suficiente para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la solución impugnada, (CSJN, 15/10/96, Unión Obrera Metalúrgica c. Estado Nacional).

Porque criticar es muy distinto a disentir, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que ésta pudiese tener. En cambio disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, (CPL de San Juan, 11/8/97, Olguin c/Lahoz), (cf.: W.O. y Glagol Press - Tel./Fax.: (+54-11) 4371-7868 - Bs. As. - Argentina - E-mail:----[EMAIL_1]----).

Consecuentemente, como se infiere de las opiniones doctrinarias y citas jurisprudenciales a las cuales adhiero, la falta de cumplimiento de la crítica concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido, traen como conclusión la declaración de deserción del recurso de apelación.

Adempero, con la amplitud que merece ser tratada la cuestión para no vulnerar el derecho de defensa de los recurrentes, puede darse una respuesta a la expresión de disconformidad de los demandados.

V. Por una cuestión metodológica, se trataran primero las quejas de los accionados y luego la del accionante.

VI. No se ha discutido que Olga Marta Olsacher de Rennella, cónyuge supérstite del actor en estos autos, fue declarada heredera del mismo por resolución jurisdiccional que en copia debidamente autenticada obra a fs. 64. La nombrada fue designada administradora judicial de la sucesión de su extinto esposo, según decisiones que en reproducción fotoestática refrendadas, lucen a fs. 22 y 65. Estos actos jurisdiccionales no han sido observados.

Si bien es cierto que al tiempo de promoverse la acción ejecutiva, había expirado el plazo por el que la Sra. de Rennella fue nombrada administradora judicial de la herencia, no es menos cierto que en la especie juega la previsión del art. 1969 del Cód.Civil pues el apoderado debía llevar a cabo actuaciones que no admitían dilación. Debe repararse en que el mandato otorgado lo era general para pleitos por la "Sucesión de Pedro Rennella". De ahí, entonces, que la ratificación de la administradora de lo actuado por su mandatario otorgue a lo llevado a cabo plena eficacia.

Así las cosas, el primer embate debe ser desestimado.

VII. La otra queja se relaciona con la inhabilidad del contrato de locación como título ejecutivo, habida cuenta que se persigue el cobro de mercedes locativas devengadas con posterioridad al vencimiento del plazo convenido para la vigencia de aquél.

Por vía de la defensa de inhabilidad de título sólo es dable la discusión sobre las formas extrínsecas del título que sirve de base a la ejecución, no pudiéndose discutir mediante esta defensa la causa de la obligación.

Obviamente, el argumento hecho valer para fundar la defensa articulada no ataca al título sino que se dirige a discutir la causa de la obligación de manera tal que el recurso queda vacío de contenido.

VIII. Procede ahora ocuparse de la pretensión del actor que, para mantener el valor adquisitivo de su crédito, procura que se aplique una pauta de actualización monetaria declarando -de ser necesario- la inconstitucionalidad de las normas que lo prohíben. El contrato de locación que vinculara a los litigantes, contenía un acuerdo de voluntades acerca del precio del alquiler que se fijó en dólares estadounidenses.

En lo que concierne a la facultad judicial de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, un reciente fallo de un tribunal de Capital Federal discurre sobre ella con apreciaciones que son compartidas. Recordemos, además, que la ley 23.928 prohíbe -aun en la modificación en su art. 10 introducida por la ley 25.561- que a partir del 1° de abril de 1991 se incluyan en los contratos de alquiler cláusulas contractuales de estabilización.

En el caso traído a colación, se alza el ejecutado contra el pronunciamiento que declara la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 8° del dec. 214/2002 y la ley 25.561, disponiendo que el monto al que alude la liquidación por la que se mandó llevar adelante la ejecución, deberá representar la suma de pesos necesaria para adquirir en el mercado libre de cambios la cantidad de dólares estadounidenses.

En lo que aquí importa, se dijo:

"... Respecto de la cuestión constitucional analizada en el decisorio atacado y que es materia de agravios, esta sala se ha pronunciado (conf. R.357.361 "Torrada S. F. y otros c. Oscar Dato Robinson S.A. s/ejec. hipotecaria", del 27 de diciembre de 2002, La Ley, Supl. E. Dep. Banc. y Restric., febrero/2002, p. 72-; íd., R.361.452 "Turolla S. M. y otro c. Mazzochini J. C. y otro s/ejecución hipotecaria", y R.359.596, "Antognini S. M. y otros c. Cymment Z. y otro s/ejecución hipotecaria ambos del 6 de febrero de 2003), destacando que una primera aproximación a ella nos lleva necesariamente a señalar como ya lo hiciera este Tribunal en anteriores pronunciamientos, que la Constitución

además de organizar al estado, reconoce a los individuos un determinado "status" de derechos y libertades. Es la parte dogmática en la cual aparecen las prerrogativas de los hombres y de las instituciones, sus garantías, acciones, etc. Al investir así a los sujetos de derecho de tales facultades jurídicas, la constitución obliga a los sujetos pasivos a no conculcar esas atribuciones; es decir, veda las violaciones, los abusos, el desconocimiento de los derechos individuales. Y en esa prohibición involucra como sujeto pasivo universal a todos y a cualquiera: a los particulares, al Estado, a los funcionarios, etc. De tal modo, cualquier acto de la autoridad o de los particulares, contrario a la Constitución, puede y debe ser argüido de inconstitucionalidad.

Sin embargo la revisión judicial en juego en los planteos de inconstitucionalidad, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal, sólo es apreciable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una declaración de esta índole sino cuando ello es de estricta necesidad (conf. CS, Fallos 252:328, LA LEY, 107-601; 260:163; Gialdino, Rolando E., "Un lugar de encuentro en materia de control de inconstitucionalidad", LA LEY, 1997-C, 1013).

Por su gravedad el control de constitucionalidad resulta, entonces, la ultima ratio del ordenamiento jurídico (ver Kemelmajer de Carlucci, A., "El Poder Judicial", Ed. Depalma, 1989, ps. 235/250) y requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto (conf. CS, Fallos 156:602, 258:255, 302:1666, entre otros).

La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia no pueden prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma, ello así por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común; tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos 249:37 y sus citas -La Ley, 104-29-; Bidart Campos, Germán J., "La Corte Suprema", p. 59). Además tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no le corresponde expedirse sobre cuestiones de política económica que son privativas de los otros poderes del Estado (CS, 01/09/1992, "Propulsora Siderúrgica S.A.I.C. s/rec... de apel.", Fallos 315:1820)..."

"... De ahí que la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno sería el perjuicio que sufre el acreedor que cobre en pesos en lugar de los dólares que le eran debidos. Porque si hubiera cobrado dólares o pesos durante la vigencia de la convertibilidad, compraba lo mismo en el mercado interno. No se trata en el caso de obligaciones en las que se introdujo el signo extranjero como moneda esencial, tales como las que se deben pagar en giros sobre el exterior o las que se rigen por la ley extranjera. Pero nuestro peso, sin el apoyo del dólar, pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad, y tanto para el acreedor como para el deudor (Casiello Juan José, "¿Se pretende 'minimizar' la pesificación? Nuestra opinión sobre la pesificación de las obligaciones en mora", LA LEY, 2003-A, 1119)..."

"... Los derechos constitucionales deben ser protegidos no sólo a favor de los acreedores, sino también de los deudores que podrían encontrar vulnerados aquéllos ante el mantenimiento de las pautas contractuales en un contexto totalmente distinto e imprevisible al momento de contratar, donde los riesgos asumidos por las partes han sido superados por los parámetros que impone la realidad. No cabe duda entonces que la situación de crisis por la que atravesó y atraviesa el país amerita que se la califique de emergencia. Sin entrar a considerar las medidas económicas introducidas por los poderes a quienes la constitución le atribuyó las facultades para tomarlas (establecer el régimen monetario y cambiario de la Nación -art. 75 inc. 11, Constitución Nacional-), ni

sostener los fines por los que se recurre al estado de emergencia, lo cierto es que nos encontramos con un escenario donde le toca al Poder Judicial morigerar el impacto que las leyes impugnadas generaron sobre los contratos celebrados entre los particulares, y donde se advierte -a partir de la recomposición y los remedios que las mismas normas atacadas prevén- que el propio texto de la ley brinda herramientas para ajustar la deuda. Por tanto, no cabe sino concluir que el resultado de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas, cuando no son claramente irrazonables, puede conducir, aunque se trate de un efecto no deseado, además de un desconcierto para los ciudadanos, coadyuva a profundizar la propia crisis económica que afecta a todos por igual. En definitiva las normas imponen la necesidad de que todos soporten equitativamente las consecuencias de la emergencia de modo que nadie se beneficie con la crisis a expensas de otros. Como se ha dicho, imaginar que en una grave crisis es posible preservar inmutables las condiciones bajo las cuales se desenvuelve cada uno de los habitantes es no tener sentido de la realidad. Y de ese sentido no se puede carecer si realmente se procura administrar justicia (Ratti, Eduardo A., "La conversión a pesos de las obligaciones nominadas en dólares", LA LEY, 2002-F, 1377)..."

"... Debe efectuarse una interpretación flexible de las normas. El Código Civil está pensado para una economía estable, por lo que interpretar la ley sólo a la luz del mismo sería también inconstitucional, máxime cuando aquella otorga los mecanismos de reestructuración del contrato o remedios para compensar algún desfase. Justamente así lo previó el Codificador en la nota al art. 619 donde señala "Nos abstenemos de proyectar leyes para resolver la cuestión tan debatida sobre la obligación del deudor, cuando ha habido alteración de la moneda, porque esa alteración se ordenaría por el Cuerpo Legislativo Nacional, cosa casi imposible. La ley declararía el modo de satisfacer las obligaciones que ya estuviesen contraídas. Hoy los conocimientos económicos dan a la moneda otro carácter que el que se juzgaba tener en la época de las leyes que hicieron nacer cuestiones sobre la materia".

Devino un cambio en el régimen monetario de orden público, que se impone a las dos partes en la relación jurídica (conf. Casiello, Juan J., op. cit.), por lo que no puede ser admitida la posición que propone el traslado de todos los riesgos al deudor. No puede ser mantenido un acuerdo en el tiempo y en el espacio, cuando la nueva temporalidad indica que las condiciones se modificaron sustancialmente (conf. Ariza, Ariel, op. cit.)..."

"... La totalidad de las personas ha sufrido una pérdida del valor venal de su patrimonio, pues los bienes muebles o inmuebles han padecido una merma en su cotización. Aun cuando los inmuebles en la actualidad sean cotizados a una mayor cantidad de pesos que con anterioridad a la pesificación, nunca alcanzan al valor que representaban cuando existía la paridad con el dólar y por otra parte no debemos dejar de señalar que ya sea por la recesión o por diversos motivos, que no es del caso analizar, ese aumento nominal no se traduce por el momento en un aumento en los alquileres. No puede perderse de vista que los jueces no pueden cerrar los ojos a lo que ven, ante hechos que son de público conocimiento..."

"... Recordemos que son muchos los casos en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante fenómenos en donde por distintas circunstancias que padecía nuestra economía se afectó el poder adquisitivo de la moneda, resolvió que el mecanismo -en esos casos de actualización- para mantener el valor del capital sólo constituye un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de aquélla, mas cuando el resultado se vuelve objetivamente injusto, debe ser dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas (Fallos 315:2980; 308:815; causas: P.325.XXII. "Pronar S.A.M.I. c. Provincia de Buenos Aires s/daños y

perjuicios", 13 de febrero de 1990; C.96.XXIII. "Cukierman, Moises s/sucesión", 11 de septiembre de 1990 e I.102.XXIII. "Itkin, Mario c. Amaya, Omar Guillermo y otro", 5 de noviembre de 1991; 313:748, entre otros)...", (ver voto de los doctores Eduardo A. Zannoni, Fernando Posse Saguier y Elena I. Highton de Nolasco, CNCiv, sala F, 14/03/2003, "Ruberto, Guillermo M. c. D'Arienzo, Pablo M.", LA LEY, 2003-B, 781). IX. En el sub lite, el Inferior luego de considerar que el planteo de inconstitucionalidad de formuló intempestivamente analiza la cuestión desde el punto de vista sustancial y concluye rechazándola.

Para llegar a tal determinación, adujo el a quo que "... el hecho de haberse aplicado a la deuda emergente del contrato la multa y los intereses pactados por las partes para el caso de incumplimiento de las obligaciones (cláusula penal), solicitados por el propio accionante, sin que planteara en momento alguno la revisión de los mismos en función de los cambios operados en el sistema financiero, implica la aceptación de las consecuencias dimanadas del incumplimiento, por lo que la eventual declaración de inconstitucionalidad en nada cambiaría el importe de las sumas mandadas a pagar por la presente".

Por el Considerando VI de su resolución, el sentenciante estimó justo mandar llevar adelante la ejecución por el capital reclamado más un interés equivalente al dieciocho por ciento anual, por todo concepto, que se pactara en la cláusula sexta de la convención, mientras que rechazó el pedido de aplicar la multa prevista en la siguiente disposición en razón de que para "su cálculo y procedencia debe recurrirse a la comprobación de elementos que resultan ajenos a este tipo de procesos".

Lo atinente a los intereses y a la multa mencionada, las partes pactaron en los siguientes términos:

"... Sin perjuicio de las acciones de desalojo y cobro ejecutivo que tendrá derecho a iniciar el locador, el locatario deberá abonar sobre toda suma no pagada en término un interés diario de pesos cinco (\$5,00) para los primeros treinta días sobre cada período de renta por separado. Posteriormente se percibirá la renta más la multa antes mencionada (calculada sobre cada mes por separado) con más los intereses compensatorios del doce por ciento (12%) anual y punitivos del seis por ciento (6%) anual. O sea un dieciocho por ciento (18%) sobre saldos adeudados, quedando establecido que estos intereses serán capitalizados en forma anual... En caso de que el locatario, producido el vencimiento del contrato no lo restituyere, sin perjuicio de la acción de desalojo, se hará pasible de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del alquiler vigente por día o fracción que exceda el término de restitución pactado..."

Al respecto, vale recordar que dispone el art. 1197 del Código de Vélez que "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma".

Establece este precepto el principio que se denomina el de la "autonomía de la voluntad".

Tengo dicho que por él, las estipulaciones de las partes adquieren plena fuerza obligatoria y, por consiguiente, salvo casos anormales, no son pasibles de revisión por una de las partes o por el juez a pedido de ella.

En doctrina, se ha señalado que el principio de la "autonomía de la voluntad" tiene los siguientes alcances: a) los acuerdos que contiene el contrato, dejando de lado las excepciones expresas, deben prevalecer sobre las disposiciones de la ley y, con mayor razón, de los usos o costumbres en los casos en que ellos tengan valor legal; b) los jueces deben hacer respetar y cumplir esas convenciones y estipulaciones; c) los jueces tienen la facultad de interpretar y determinar sus alcances, en la misma forma en que lo

hacen con la ley; y d) los jueces deben pronunciarse, cuando son llamados, sobre todo lo concerniente al cumplimiento o ejecución del contrato.

Y en lo que hace a los intereses acordados, tuve oportunidad de expedirme y en la ocasión manifesté que lo apuntado, viene a cuento a partir de tres circunstancias: 1º) lo convenido oportunamente entre los litigantes, 2º) lo que entiendo por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y 3º) lo decidido por la sala laboral del Excmo. Tribunal Superior de Justicia local, en el pronunciamiento recaído en "Hernández, Juan Carlos c. Matricería Austral S. A. - Demanda - Rec. de Casación", Sentencia N° 39 del veinticinco de junio del año dos mil dos. Dije entonces, y ahora lo reitero, que "traigo a colación este criterio, por lo que antes referí respecto de la liquidación para el cumplimiento o ejecución de la sentencia.

En ese trámite procesal, no podrá dejarse de lado lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decs. regl. 529/91, y párrafos agregados por dec. 941/91 y, conforme a tales disposiciones establecerse el capital. Una vez determinado el mismo, deberá ordenarse el pago del fruto civil y, en ese orden de ideas, entiendo justo que la tasa que se aplique a tal fin, no supere -por todo concepto- el treinta por ciento (30%) anual", (conf. mi voto en "Ronchi Viveca, Ana c. Petrovsky, Gustavo M.", 15/08/2002, LLC, 2002-1441 - Sup. Esp. Rev. del Contrato 2003 (febrero), 119).

X. Así las cosas, a la luz de lo convenido por las partes soy de opinión de que la cuestión traída a nuestra consideración por la parte demandante puede ser resuelta sin necesidad de apelar a la declaración de inconstitucionalidad pedida.

Del acuerdo de voluntades, se desprenden distintos elementos convenidos por las partes para mantener incólume la acreencia del locador a través de la aplicación de intereses o multas.

Si se toma el interés diario convenido de cinco pesos, se concluirá en que en un mes de treinta días ese monto asciende a ciento cincuenta pesos que representan el 39,4736 % del canon locativo mensual pactado en trescientos ochenta dólares estadounidenses (U\$S380) que a la época de la celebración del contrato equivalían a trescientos ochenta pesos (\$380).

Esa tasa de interés se presenta desmesurada por alta y como la misma parte apelante admitió la morigeración, valoro ecuánime mantener el criterio antes expuesto y establecer como tope anual de aquélla el treinta por ciento por todo concepto. Dejo de lado, de propósito, la consideración de la multa concertada, pues el juez de primer grado no la aplicó y en la Alzada tal decisión no ha sido motivo de ataque expreso ya que se la apreció como parte integrante de la indemnización buscada por vía de los intereses.

XI. Se pretende la aplicación de la sanción prevista en el art. 83 de la ley ritual a la parte recurrente.

En el presente se configura la hipótesis planteada en la norma citada toda vez que se vislumbra conducta procesal maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora.

Ello es evidente a poco que se repare en la carencia de fundamento de los incidentes, del recurso mal concedido y el interpuesto en esta ocasión, todo lo cual configura una conducta procesal temeraria.

"Esta se refiere al contenido de las pretensiones, y es por ello que Palacio, nos habla de que la temeridad "Se configura, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sinrazón". Nos indica la presencia de dos elementos para configurar esta conducta: "... el elemento objetivo representado por la falta de fundamento o por la injusticia de la pretensión o de la oposición. Es además necesario el factor subjetivo que se manifiesta a través de la conciencia de que tales circunstancias concurren en el caso concreto... Fassi ... define al litigante temerario como "inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin medir sus consecuencias, carente de fundamento, razón o motivo...", (Magdalena

López Carusillo en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba", dirigido por Rogelio Ferrer Martínez, p. 215, Ed. Advocatus, Cba., 2000).

Lo apuntado hace procedente la aplicación de la sanción solicitada, habida cuenta que no se vislumbra nada más que un ánimo dilatorio en la interposición de los incidentes y de los remedios desestimados.

En tales circunstancias, es ajustado a derecho establecer una multa, a favor del ejecutante y a cargo de la parte recurrente, equivalente al veinte por ciento del máximo de los honorarios posibles, en cada una de las instancias y por las cuestiones decididas.

XII. Así voto.

El doctor *Sahab* dijo:

I) Que, sobre la cuestión de fondo, comparto los argumentos y conclusiones del doctor Sarsfield Novillo, y me expido en igual sentido.

II) Que, respecto de la sanción del art. 83 CPC solicitada por la actora, mi opinión es que no procede. Paso a exponer las razones.

Que, en primer lugar, existe un impedimento de orden procesal y es el que impone la parte final de la norma en cuanto dice que la sanción "será impuesta en la resolución que pone fin a la instancia o al juicio". Lo que el requirente solicita en la contestación de agravios de fs. 125 comprende actos procesales y conductas de la demandada que tuvieron lugar en la instancia anterior y en la que no se pidió su aplicación, con lo que debe considerarse que ha consentido. Ahora no puede volver contra sus propios actos y conductas (arts. 1071 y 1198, CC).

Que, por otro lado, la circunstancia de que la demandada haya ofrecido una prueba (informativa - exhorto) y luego no la haya diligenciado, no configura inconducta procesal, no habiendo el solicitante de la sanción demostrado qué perjuicio o dilación le produjo.

Que, las restantes enunciaciones que hace en el punto 4.4. del referido escrito de fs. 125, comprenden el retiro de expediente con recibo y en casi todos los casos aparece proveído el expediente para agregar de la actora, en la misma fecha o inmediatamente de solicitado el emplazamiento para devolver, con lo que, en relación al escrito proveído, aparece como retirado para presentarlos (reposición; informe; apelación; etc.). Y en todo caso, tampoco configuran las conductas sancionables por la aludida norma procesal. En todo caso, pudo haber solicitado la sanción del art. 74 CPC, cosa que tampoco hizo oportunamente.

Que, el art. 83 CPC dispone en su última parte que "la resolución será recurrible". Mas decisión tan severa, que implica ejercicio de autoridad punitiva, ha sido vista siempre como peligrosa por la dificultad de separar el límite del ejercicio legítimo del derecho de defensa de la litis temeraria (confr.: Colombo, Carlos J., CPCN Anotado y Comentado, Bs. As., 1964, Ed. Abeledo Perrot, p. 143 y citas de Chiovenda contenidas allí); estamos frente a una norma huérfana de especificidad en las conductas a sancionar, lo que imperativamente conduce a una aplicación prudente. Y en esa falta de especificidad, se halla también la última parte del dispositivo al señalar que la resolución es apelable.

Que, sobre el punto se ha dicho que "es verdad que la posibilidad de recurrir la sanción (última parte del art. 83, CPC) preserva "a posteriori" ese interés pero, para castigar actos cumplidos por profesionales asistiendo a los litigantes y no "nomine proprio". Con mayor razón si se tiene en cuenta que, en la especie, se multaría un acto ya consumado y, por ende, la sanción sólo podría satisfacer una finalidad punitiva, sin disuasión y compulsión que, por lo contrario, se verifica en la multa progresiva por retención de expediente (art. 74, CPC). Además, la conducta procesal maliciosa o temeraria puede

ser jurisdiccionalmente sancionada con la pérdida del derecho a percibir honorarios (art. 44, ley 8226)" (C8aCCCba, 22/09/97, SJ N°1214, T.79, p. 492).

Que, en definitiva es una cuestión de puro derecho, que no es otra cosa que la inteligencia de una norma procesal novedosa que deja en los jueces la difícil tarea de estimar y sancionar "la inconducta procesal, no el abuso del proceso. Es decir, sanciona cualquier acto, de las partes o de sus letrados (procuradores, patrocinantes o apoderados) que se realice en el marco de la contienda procesal y no sanciona al querulómano, al inventor de pleitos, al que litiga sin razón valedera. La "sanción" para éste, es cargar con las costas del proceso, pero no puede imponérsele una multa, por no tener derecho o razón para litigar" (Rodríguez Juárez- Píttaro, "Código Procesal Civil y Comercial", Cba., 1996, Ed. Alveroni, p. 53). También en el orden nacional la jurisprudencia aconseja total prudencia en la aplicación de sanciones procesales para evitar la violación al derecho de defensa (CNCiv., La Ley, 14/03/96; La Ley, 132-1034 y sigtes.; 133-637).

Que, bien señala Couture que la derrota no siempre significa que el litigante carece de razón, porque muchas veces circunstancias procesales -como la que he apuntado- de carácter contingente, deciden la suerte del litigio. Por ello, no todo derrotado es un "improbis litigator", lo que justifica tener extrema precaución en la diferenciación de conductas para sólo sancionar aquellas en la que es indudable la temeridad o malicia, o, incluso, la evidente mala fe, nada de lo cual se advierte en el caso bajo examen (confr., "Estudios de derecho procesal civil", Bs. As., 1950, t. 3, p. 235 y sigtes.).

La dilación de un trámite no está necesariamente ligada a una conducta descalificante o sancionable, pues muchas veces esa dilación escapa de lo disponible por los propios litigantes.

Que, en conclusión, el caso bajo examen en modo alguno autoriza la aplicación de la sanción peticionada en tanto la conducta desplegada por la demandada no ha salido del marco del legítimo ejercicio del derecho de defensa, dentro del marco impulsorio dado por la actora.

El doctor *Liendo* dijo:

I. Por considerar ajustado a derecho las argumentaciones expuestas por el Vocal de primer voto, me adhiero al mismo propugnando, en consecuencia, idéntica solución a la cuestión bajo análisis.

II. En relación al punto de divergencia existente, relativo a la sanción prevista por el art. 83 del CPC, adhiero a la solución propuesta por el doctor Sahab por los siguientes fundamentos.

Se solicita por la parte actora se resuelva el pedido de aplicación de la sanción del art. 83 del CPCC a la contraria.

El citado dispositivo legal impone a las partes, sus letrados y apoderados el deber de actuar con probidad y buena fe, sancionando la conducta que implique una desviación de tales principios.

Este incumplimiento tiene su expresión en la conducta manifiestamente maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora, siendo el carácter de manifiesto y ostensible de la mala fe esencial, porque de lo contrario se corre el riesgo de cercenar el derecho de defensa de la parte.

Comentando este artículo Vénica, citando a Clemente Díaz, nos enseña que "... la sola falta de razón no es motivo de temeridad, pues de lo contrario, todo litigante que perdiera el pleito sería pasible de sanción... Se trata de una cuestión de hecho sobre la cual es muy difícil dar fórmulas precisas: la conducta temeraria se revela al juez, a través de toda la actuación en el proceso, por lo absurdo, caprichoso, etc., de las pretensiones o defensas...".

Agregando posteriormente "... Por ello es que las normas que sancionan la inconducta están destinadas exclusivamente a casos de real gravedad. Así el art. 83 exige que la temeridad o malicia deban ser manifiestas para ser pasibles de sanción, por lo que en caso de duda razonable, respecto de si la actuación es maliciosa o no, debe estarse por la amplitud de la defensa." (Vénica, Oscar Hugo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba", t. I, p. 237).

Sobre la base de lo dicho entiendo que no existe mérito suficiente para que la sanción que se solicita sea impuesta a la demandada.

Comparto en tal aspecto la valoración efectuada por el Vocal Ricardo Jesús Sahab en relación a que los actos endilgados como susceptibles de sanción, consistentes en el ofrecimiento de prueba luego no diligenciada, así como los sucesivos retiros del expediente y sus emplazamientos correspondientes que menciona, no encuadran en alguna de las conductas descriptas por el art. 83 del rito o, por lo menos, generan una duda razonable que, por lo tanto, obsta la aplicación de la sanción requerida puesto que siempre corresponde inclinarse por la amplitud de las garantías de la defensa en juicios ante las situaciones reseñadas. Así voto.

2ª cuestión. - El doctor *Novillo* dijo:

Propongo que se desestime el recurso de apelación de la demandada y se recepte el de la parte actora y, en consecuencia, se revoque parcialmente la decisión cuestionada disponiendo que los intereses que devenga la obligación insoluta sean calculados desde la época de la mora y hasta el día de su efectivo pago con un tope del treinta por ciento (30%) anual, con costas a cargo de la accionada; se deje sin efecto la regulación de honorarios practicada y se establezcan como retribuciones para el doctor H. E. R. por su trabajo en la instancia anterior en la suma de Pesos Un mil trescientos cuarenta y cinco con trece centavos (\$1345,13) que equivale al punto medio de la escala legal y por las labores en la Alzada la cantidad de Pesos Quinientos treinta y ocho con cinco centavos (\$538,05) que representa el cuarenta por ciento de aquella pauta calculado sobre lo que fuera motivo de discusión en esta Sede y que, por último, se imponga una multa, a favor del ejecutante y a cargo de la parte accionada, equivalente al veinte por ciento del máximo de los honorarios posibles, en cada una de las instancias y por las cuestiones decididas, (arts. 130 y 83, CPCC y 25, 34, 36, 37, 29, 78 y conc., ley 8226).

El doctor *Sahab* dijo:

Propongo que se desestime el recurso de apelación de la demandada y se recepte el de la parte actora y, en consecuencia, se revoque parcialmente la decisión cuestionada disponiendo que los intereses que devenga la obligación insoluta sean calculados desde la época de la mora y hasta el día de su efectivo pago con un tope del treinta por ciento (30%) anual, con costas a cargo de la accionada; se deje sin efecto la regulación de honorarios practicada y se establezcan como retribuciones para el Dr. H. E. R. por su trabajo en la instancia anterior en la suma de pesos Un mil trescientos cuarenta y cinco con trece centavos (\$1345,13) que equivale al punto medio de la escala legal y por las labores en la Alzada la cantidad de pesos Quinientos treinta y ocho con cinco centavos (\$538,05) que representa el cuarenta por ciento de aquella pauta calculado sobre lo que fuera motivo de discusión en esta Sede. Desestimar la sanción del art. 83 del CPC solicitado por la parte actora.

El doctor *Liendo* dijo:

Propongo que se desestime el recurso de apelación de la demandada y se recepte el de la parte actora y, en consecuencia, se revoque parcialmente la decisión cuestionada disponiendo que los intereses que devenga la obligación insoluta sean calculados desde la época de la mora y hasta el día de su efectivo pago con un tope del treinta por ciento (30%) anual, con costas a cargo de la accionada; se deje sin efecto la regulación de

honorarios practicada y se establezcan como retribuciones para el Dr. H. E. R. por su trabajo en la instancia anterior en la suma de pesos Un mil trescientos cuarenta y cinco con trece centavos (\$1345,13) que equivale al punto medio de la escala legal y por las labores en la Alzada la cantidad de pesos Quinientos treinta y ocho con cinco centavos (\$538,05) que representa el cuarenta por ciento de aquella pauta calculado sobre lo que fuera motivo de discusión en esta Sede. Desestimar la sanción del art. 83 del C.P.C.

solicitado por la parte actora.

Atento el resultado de los votos emitidos, por mayoría se resuelve: 1. Desestimar el recurso de apelación de la demandada y receptar el de la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la decisión cuestionada disponiendo que los intereses que devenga la obligación insoluta sean calculados desde la época de la mora y hasta el día de su efectivo pago con un tope del treinta por ciento (30%) anual. 2. Costas a cargo de la accionada. Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada y establecer como retribuciones para el doctor H. E. R. por su trabajo en la instancia anterior en la suma de pesos un mil trescientos cuarenta y cinco con trece centavos (\$1345,13) y por las labores en la Alzada la cantidad de pesos Quinientos treinta y ocho con cinco centavos(\$538,05).

3. Desestimar la sanción del art. 83 del CPC solicitada por la parte actora. - *Mario Sarsfield Novillo.* - *Ricardo J. Sahab.* - *Héctor H. Liendo.*